

1500964-56.2021.8.26.0559

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria Letícia Pozzi Buassi

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/11/2022

... de evidenciarem terem os acusados praticado o tráfico ilícito.

Contudo, aponta a Jurisprudência dos Tribunais não ser necessária a prova efetiva do tráfico para a formação do Juízo de certeza, bastando a comprovação pelos elementos que cercam o agente. Confira-se: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

4ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, São José do Rio Preto-SP - cep 15010-070

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500964-56.2021.8.26.0559 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500964-56.2021.8.26.0559

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

JULIO CESAR FARIAS DE OLIVEIRA e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juíza de Direito: Dra. Maria Letícia Pozzi Buassi

Vistos.

JULIO CESAR FARIAS DE OLIVEIRA e LORENA GABRIELY RODRIGUES PEREIRA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c. c. o art. 61, inc. II, "j", do Cód. Penal, porque no dia 07 de julho de 2021, por volta das 16h, na Rua Pedro Demonte, 73 e na Rua Padre José Bento, 43, nesta cidade e comarca, guardavam, mantinham em depósito e transportavam, para futura entrega a terceiros, três porções de "maconha", pesando 112,06g; cinco porções de cocaína, na forma de "crack", pesando 806,05g; trinta e uma porções de cocaína, pesando 40,06g; e uma porção maior de "maconha", pesando 343,43g, substâncias estas entorpecentes e determinantes de dependência física e psíquica, o que faziam sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Portavam, ainda, os réus, duas balanças de precisão, dois rolos de plástico filme, diversas embalagens plásticas, dois aparelhos celulares e R\$ 72,00.

Policiais militares, em patrulhamento de rotina, abordaram os réus na condução do veículo "VW/Gol", localizando-se, no interior, três porções de "maconha", bem como, em revista pessoal, os celulares e o dinheiro.

Em seguida, após indicação dos réus, efetuaram os agentes diligências na residência

destes, onde encontraram o restante das drogas e os petrechos. Oferecida a denúncia foram os réus notificados e apresentaram defesa prévia. Recebida a denúncia designou-se audiência de instrução, na qual foram ouvidas duas testemunhas comuns e duas apontadas pela defesa. Após, foram interrogados os réus. Em debate, o representante do Ministério Público, sustentando demonstradas a materialidade dos fatos e a autoria do delito, requereu a condenação dos acusados nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição dos réus sustentando, em suma, insuficiência de provas a delinear o crime. É o relatório. DECIDO.

Por óbvio, inexistente violação ilícita do domicílio, pois, conforme narrado pelos policiais, sob o crivo do contraditório, o ingresso no imóvel decorreu, por primeiro, ante ao estado de flagrância, constatado pelo encontro das porções dos entorpecentes durante abordagem inicial, e, ao depois, ante autorização dos réus, que, inclusive, acompanharam toda a diligência de busca no imóvel. Em se tratando de delito de tráfico de drogas, enquanto o agente possuir substâncias tóxicas, poderá ser preso em flagrante, tratando-se, pois, de crime permanente, propiciando a violabilidade do domicílio, nos termos do art. 5º, inc. XI, da Constituição Federal. Assim, em razão do estado de flagrância do denunciado, excepcionada está a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, devendo ser, portanto, afastada a alegação de irregularidade da diligência policial. Nesse sentido: "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. INGRESSO FRANQUEADO. LEGALIDADE DA MEDIDA. PROVA LÍCITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O mandado de busca e apreensão é desnecessário quando se trata de situação de flagrante delito por crime permanente, como no presente caso (art. 33 da Lei nº 11.343/06). 2. O artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal garante ao indivíduo a inviolabilidade de seu domicílio, tal direito não é absoluto, uma vez que, tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio do acusado, não havendo se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida (HC n. 306.560/PR, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 18/8/2015, DJe 1º/9/2015). 3. Uma vez franqueada a entrada dos policiais responsáveis pelo ato, torna-se dispensável o mandado judicial, afastando-se, portanto, qualquer ilegalidade (HC n. 310.338/SP, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 28/4/2015, DJe 18/5/2015). 4. Para rever a conclusão da instância de origem, quanto à ausência de autorização para a entrada no domicílio, seria indispensável a revisão do conjunto fático-probatório, providência que não encontra espaço em recurso especial, em razão da vedação da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido." (STJ, REsp 1.909.082-AgRg/MG, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 02.02.2021). Afastada a preliminar, passo à análise do mérito.

A materialidade dos fatos vem comprovada por intermédio do auto de exibição e apreensão de fls. 13/15, que revela o encontro dos entorpecentes, dos rolos de plástico, das balanças, das embalagens plásticas, dos celulares e do dinheiro. Há, ainda, o laudo de constatação de fls. 59/62 e o laudo de exame químico toxicológico de fls. 184/185, concludentes no sentido de se tratar de Tetrahydrocannabinol – THC e de cocaína, as substâncias encontradas. Os petrechos foram vistoriados (fls. 128/130). A perícia efetivada nos aparelhos celulares foi acostada às fls. 195/200. Na fase policial, exerceu o réu Júlio César a prerrogativa constitucional de permanecer calado. Em Juízo, confessou o réu a prática do comércio ilícito. Explicou ter deixado a corré no veículo, enquanto entrou na residência dele e pegou o tóxico que guardava.

Recebia R\$ 200,00 por semana para a guarda do produto, sendo que, em cada entrega, perceberia novos valores. Disse não conhecer a ré, a existência da droga. Fantasiosa e descompassada da realidade a fala do réu no sentido de entrar na casa dele e sair com lasanha, que entregou para segurar a ré. Qual o motivo de sair, o réu, com a ré, e carregarem lasanha? Nenhum.

Em ambas as manifestações, disse a ré estar no veículo com o primo Júlio César quando abordados, tendo os agentes encontrado três porções de "maconha", pertencentes ao corréu. Acrescentou desconhecer a existência de drogas no imóvel indicado por Júlio César.

A confissão quanto à venda de tóxico, pelo réu, acompanha tentativa de afastar a responsabilidade da ré, sem sucesso, neste diapasão, reveste-se.....

Contam os policiais terem, em patrulhamento, abordado os réus no veículo "VW/Gol", localizando-se, em uma vasilha plástica, na posse de Lorena, três porções de "maconha", bem como, nas vestes de ambos os acusados, os celulares e o dinheiro. Explicaram o encontro, no dormitório do imóvel indicado por Júlio César, no guarda-roupa, o restante das substâncias ilícitas e os petrechos. Para tais testemunhas, ambos os denunciados disseram receber dinheiro, semanalmente, para guarda do tóxico, bem como realizarem, esporadicamente, a comercialização, sendo que, inclusive, no momento da abordagem, estariam em deslocamento para entrega das porções de "maconha" a um comprador.

Vale lembrar que o fato de agentes que participam de diligências serem testemunhas sobre estas, torna o relato apresentado mais rico em detalhes e, por isso, mais digno de fé.

No caso em tela as declarações apresentaram-se de forma harmônica e coesa com o restante da prova, razão pela qual não podem ser desconsideradas, inexistindo qualquer motivo para que quisessem os policiais militares incriminar os réus ou forjar o crime. A jurisprudência é uníssona ao reconhecer a validade das declarações prestadas, em juízo, por policiais. Neste sentido o Supremo Tribunal Federal: "o valor do depoimento pessoal dos servidores policiais especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC 73.518/SP, rel. Min. Celso de Mello, DJe 14.03.2011).

As testemunhas ouvidas em nome da defesa nada acrescentaram ao deslinde da questão. Urge consignar ser grande a quantidade de droga apreendida em comparação à condição financeira dos réus, que não comprovaram relação de emprego, logo, seria imprópria somente a eventual uso, sendo a guarda, transporte e negociação do produto, medida impositiva.

Como não se produziu prova a contrariar o já citado auto de exibição e apreensão, o tráfico é consequência lógica das provas colhidas.

Dessa forma, verifica-se não existirem apenas indícios de prova, mas sim clareza e harmonia entre elas, no sentido de evidenciarem terem os acusados praticado o tráfico ilícito.

Contudo, aponta a Jurisprudência dos Tribunais não ser necessária a prova efetiva do tráfico para a formação do Juízo de certeza, bastando a comprovação pelos elementos que cercam o agente. Confira-se: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 4. As instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático probatório amealhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Por essas razões, mostra-se inviável a desclassificação da conduta imputada ao réu, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir pela condenação do agente, desde que o faça fundamentadamente,

exatamente como verificado nos autos. 5. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. 6. Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" –, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso" (STJ, AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020).

O que importa, no caso, é ter sido o entorpecente localizado com os réus, em situação de comercialização, o que acontecia com envolvimento de ambos. Estão as provas testemunhal e técnica em perfeita harmonia, permanecendo isolada a versão de Lorena quanto a não ser possuidora do tóxico, que em conjunto com o corréu comercializava.

Além disso, a quantidade da droga apreendida e a forma de embalagem, somadas às circunstâncias acima analisadas, nos moldes do art. 239 do Cód. de Proc. Penal, levam à dedução de que seria por ambos mantidas em depósito e posta em comércio, até porque, não contam os réus com situação financeira que os permita manter tal quantidade de droga para outro fim.

Além disso, a condição de usuário não afasta a de traficante.

Por fim, vale observar que as finalidades da agravante prevista no art. 61, inc. II, "j", do Cód. Penal, são a proteção da sociedade, bem como punição mais rigorosa da conduta de quem, valendo-se das facilidades do contexto calamitoso, pratica delitos.

In casu, não havendo nexos causal entre a situação de pandemia e a conduta dos réus, é de rigor o afastamento da mencionada agravante. Nesse sentido: "Primeiramente, faz-se necessário afastar a aplicação da agravante do art. 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, pois não restou devidamente comprovado nos autos que o réu se aproveitou das circunstâncias de fragilidade, vulnerabilidade ou incapacidade geradas pelo estado de calamidade pública decretado em virtude da pandemia do COVID-19." (TJSP, 1ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 1512067-20.2020.8.26.0228, Rel. Andrade Sampaio, 12.02.2021).

Convencida da responsabilidade penal dos réus, passo a individualizar as penas.

- JÚLIO CÉSAR FARIAS DE OLIVEIRA:

- art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06: Tendo em vista os elementos norteadores do art. 59 do Cód. Penal, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em razão da elevada quantidade e da variedade de tóxico apreendido.

Verificada a reincidência (fls. 254/262), incide a circunstância agravante prevista no art. 61, inc. I, do Cód. Penal, que se compensa com a confissão da autoria, circunstância atenuante contida no art. 65, inc. III, "d", do Cód. Penal.

Não há causas de aumento ou diminuição da pena.

- LORENA GABRIELY RODRIGUES PEREIRA:

- art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06: Tendo em vista os elementos norteadores do art. 59 do Cód. Penal, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em razão da elevada quantidade e da variedade de tóxico apreendido.

Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes e nem causas de aumento ou diminuição da pena.

O regime inicial de cumprimento da pena, para ambos os réus, é o fechado (art. 1º, § 1º, da Lei n.º 11.464/07).

Destaco que quando da fixação do regime inicial de cumprimento da pena para o réu Júlio César, já se observou o período de prisão provisória, nos termos do § 2º do art. 387 do Cód. de Proc. Penal.

O fato de ter o réu Júlio César respondido encarcerado à instrução do feito não

implica, com a prolação desta sentença, na concessão de regime menos gravoso. Neste sentido: "(...) PENA. DETRAÇÃO. CÔMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA PARA FINS DE DETERMINAÇÃO DO REGIME INICIAL DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - ART. 387, § 2º, DO CPP, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 12.736/12. FIXAÇÃO A SER EFETUADA PONDERANDO-SE CONJUNTAMENTE O QUANTUM DA PENA APLICADA COM AS CONDIÇÕES SUBJETIVAS PREVISTAS NOS ARTS. 33, § 3º E 59 DO CP. ENTENDIMENTO. O merecimento do reeducando integra necessariamente os requisitos para sua promoção de regime, sendo vital à individualização da pena que a promoção não se dê de modo automático, como sugeriria uma interpretação desavisada e superficial da redação do § 2º, do art. 387, do CPP, após a reforma de 2012, mesmo porque tal depende do preenchimento de requisitos tanto objetivos quanto subjetivos. Deve-se ressaltar que a lei a ser utilizada por ocasião da fixação do regime inicial é o CP e não o CPP. Na medida em que a reforma empreendida pela Lei n. 12.736/2012 não revogou o art. 33, § 3º, do CP, a fixação de regime inicial deve ainda considerar obrigatoriamente se foram ou não preenchidas as condições subjetivas, previstas no art. 59 do mesmo estatuto penal. A posterior progressão de regime vem, ademais, necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza diversa. Para que seja efetuada aludida progressão, destaque-se, faz-se necessário que sejam sopesados os respectivos requisitos pelo Juiz natural da causa, que é o Magistrado das Execuções Penais, e não o prolator da sentença". (TJSP, Apelação Criminal nº 1500199-27.2019.8.26.0407, Rel. Des. Grassi Neto, 9ª Câmara de Direito Criminal, julgado em 19/11/2020). Ainda: "Descabe, igualmente, pleitear aqui regime prisional mais brando com base na atual redação do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, o que ora se destaca, quer à luz do invocado princípio da suficiência da sanção, quer porque a consideração do tempo de prisão provisória não prescindiria de demonstração cabal de bom comportamento carcerário e de condições subjetivas favoráveis, tal como se exige para a avaliação do cabimento de progressão. Se assim não fosse, ficaria ferida de morte a lógica do sistema penal. E tal demonstração não existe nos autos." (TJSP, Apelação Criminal nº 1500128-92.2021.8.26.0559, Rel. Fátima Gomes, 9ª Câmara de direito Criminal, julgado em 31.03.2022).

Deixo de aplicar o § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, a reincidência de Júlio César e o concurso de agentes, fatos a apontar maior periculosidade dos réus, indicando dedicarem-se à atividades criminosas, mesmo porque, não existe comprovação de atividade laborativa.

Neste sentido, o RHC nº 116.926, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 4/9/13, no qual se decidiu que: "a conduta social do réu, o concurso de agentes, a quantidade e a natureza do entorpecente, os apetrechos utilizados e as circunstâncias em que a droga foi apreendida podem constituir o amparo probatório para o magistrado reconhecer a dedicação do réu à atividade criminosa. Precedentes: RHC 94.806/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 16/04/2010; HC 116.541/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 6/6/2013; HC 98.366/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 5/2/2010" (g.n.). O valor unitário do dia-multa é o mínimo legal, considerada a situação econômica dos acusados (art. 43, caput, da Lei nº 11.343/06).

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal e condeno JÚLIO CÉSAR FARIAS DE OLIVEIRA, R.G. n.º 47.128.55 e LORENA GABRIELY RODRIGUES PEREIRA, R.G. n.º 54.681.8039, cada um, a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão mínima ao dia-multa, por terem infringido o art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 c. c. o art. 29, caput, do Cód. Penal.

Não poderá o réu Júlio César apelar desta sentença em liberdade, nos moldes do art. 1º, § 3º, da Lei nº 11.464/07.

Ainda que assim não fosse, em sendo necessária a prisão no correr da instrução do feito, a prolação desta sentença condenatória apenas reforça os motivos ensejadores do afastamento do réu do convívio social, por garantia da ordem pública.

Recomende-se o réu Júlio César no presídio onde se encontra, expedindo-se mandado de prisão, se necessário.

Porque aguardou a ré Lorena a instrução do feito em liberdade, faculto eventual apelação nesta mesma condição, devendo-se observar as medidas cautelares determinadas às fls. 96/98.

A pena pecuniária será atualizada a partir da data do fato, uma vez que a correção monetária não apresenta nenhum plus, mas sim tentativa de reposição do poder aquisitivo da moeda.

Força concluir ainda, que a multa não corrigida perde o caráter aflitivo, tornando inútil a imposição, inatendidas as finalidades da sanção penal de punição, dissuasão e reeducação dos delinquentes.

Observados o art. 63 da Lei nº 11.343/06 e o art. 91, inc. II, "a" e "b", do Cód. Penal, DETERMINO O PERDIMENTO dos petrechos, porque utilizados como instrumentos do crime, bem como do dinheiro e dos celulares (fls. 13/15), pois obtidos em razão do comércio ilícito de drogas, conforme prova colhida. Para tanto, oficie-se ao FUNAD. Após o trânsito em julgado, nos termos do art. 72 da Lei nº 11.343/06, oficie-se à Autoridade Policial para que se proceda a destruição das amostras de entorpecente guardadas para contraprova.

Custas na forma da Lei nº 11.608/03.

P.R.I.C.

São José do Rio Preto, 09 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA